

1500068-60.2020.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500068-60.2020.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500068-60.2020.8.26.0587 - Controle nº 2020/000133

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO MÁRCIO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 77/80, no dia 28 de janeiro de 2020, às 10h00min, na Avenida Netuno, nº 988, Canto do Mar, na cidade e comarca de São Sebastião/SP, nas imediações de estabelecimentos de ensino e sedes de entidades sociais e culturais, FRANCISCO MARCIO DE LIMA, qualificado a fls. 07 e 18, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de maconha, com peso bruto de 6,6g e 04 (quatro) porções de cocaína, na forma de "Crack", com peso bruto de 4,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação preliminar de fls. 08/09 e exame químico-toxicológico de fls. 72/74). Em razão destes fatos, o réu FRANCISCO MARCIO DE LIMA, qualificado a fls. 07 e 18, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33 c.c. art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006. Preso em flagrante delito, foi o réu posto em liberdade sem pagamento de fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls.

51/53).

Recebida a denúncia (fls. 85/86), sobreveio informação do descumprimento da medida imposta, consistente em manter seu endereço atualizado perante o juízo (fls. 52). Dessa forma, com fulcro no artigo 311 do CPP, foi revogado o benefício e decretada a prisão preventiva do réu Francisco, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução (fls. 117/118).

O réu foi citado por edital, não compareceu e não constituiu defensor, motivo pelo qual foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o processo e o prazo prescricional.

Aos 13/08/2021 o réu FRANCISCO MÁRCIO DE LIMA foi preso por força de prisão preventiva decretada nos presentes autos (fls. 150).

O réu foi citado (fls. 186/187) e apresentou resposta à acusação (fls. 193).

Foi revogada a suspensão do processo e determinou o prosseguimento dos presentes autos, nos termos do art. 366, § 2º, do C.P.P. Mantido o recebimento da denúncia (fls. 194/195), em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se, após, o acusado (fls. 246/248).

Em debates, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória, ao passo que a Defesa, sustentando insuficiência de provas, requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, no que tange a dosimetria, postulou a fixação da pena no mínimo legal. Havendo majoração da pena base, seja aplicada a atenuante da confissão extrajudicial para o fim de se restabelecer a pena base. Seja, também, aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, que seja fixado regime aberto e, ainda, pugnou que seja substituída a pena corporal por penas restritivas de direitos.

Foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls.236/237).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência de fls. 11/13, no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 08/09 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 103/105, que revelou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, na forma de "Crack", nas substâncias apreendidas. Todavia, não foi realizada perícia técnica a fim de se constatar que a traficância se deu de fato a uma distância próxima de estabelecimentos de ensino e sedes de entidades sociais e culturais.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Na fase inquisitiva, o réu FRANCISCO MARCIO DE LIMA preferiu manter-se calado (fls. 07). Da mesma forma, em juízo, o réu FRANCISCO optou por permanecer em silêncio.

O policial civil, ANDRÉ ARAÚJO MACIEL, em juízo, informou que não se recorda dos fatos.

Noutro giro, o policial civil, RENATO CARVALHO DE ARAÚJO, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que estavam em uma operação com vistas à repressão do Tráfico de Entorpecentes na região. Salientou que a região do bairro da Enseada é conhecida pela traficância. Recorda-se que - na data dos fatos - deslocavam-se pela avenida do referido bairro, quando suspeitaram de dois indivíduos que estavam sentados numa calçada, perto de uma Igreja, resolvendo então abordá-los e revistá-los. A garota, menor de idade, portava um cigarro de "maconha". O indivíduo (Francisco Márcio de Lima) trazia consigo, debaixo do chinelo, pequena quantidade de entorpecentes. Indagado, Francisco admitiu que estava ali comercializando drogas. À Defensora respondeu: não havia visto o acusado em abordagens anteriores; Atua na região dos fatos em algumas equipes; Nunca havia visto o acusado.

Pois bem.

Em ambas as fases o réu permaneceu calado.

Por outro lado, o policial civil Renato Carvalho, em juízo, com rigor de detalhes, narrou que estavam pelo bairro da Enseada, nesta cidade, em região conhecida pelo comércio de drogas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Devidamente abordados, logram êxito em localizar com a garota um cigarro de "maconha". Com o acusado, debaixo do chinelo, localizaram entorpecentes. Indagado, Francisco admitiu que estava ali comercializando drogas.

O policial prestou depoimento coeso, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e goza de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que o policial tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seu depoimento constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação. Recorde-se que, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar a eficácia probante a seu testemunho que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seu relato, à míngua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, conforme pugnou a combativa defesa. Ademais, conforme mencionado pelo policial, o acusado confessou que estava comercializando entorpecentes. Ademais, o

réu não trouxe nenhuma comprovação de que passou por algum tratamento por conta de eventual dependência química; não comprovou que exercia atividade lícita; não justificou o que fazia no local conhecido pelo comércio de drogas. Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Quanto à causa de aumento de pena referente ao artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, verifico que não restou cabalmente comprovado nos autos, já que não foi realizada perícia técnica a fim de se constatar que a traficância se deu de fato a uma distância próxima de estabelecimentos de ensino e sedes de entidades sociais e culturais, devendo por isso ser afastada ante a insuficiência de provas para a sua aplicação no caso concreto.

Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação dos acusados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Resta, enfim, a fixação da pena, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo em fls. 90/92 que o réu não ostenta Maus antecedentes. Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da pequena quantidade e variedade de entorpecente apreendido (04 porções de maconha, com peso bruto de 6,6g e 04 porções de cocaína, na forma de "Crack", com peso bruto de 4,8g) na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes, isto porque, a meu sentir, o legislador infraconstitucional, ao definir a pena mínima do crime de tráfico de entorpecentes em 05 (cinco) anos de reclusão, já abarcou condutas como a que foi praticada pelo acusado, mais especificamente no que diz respeito a quantidade e variedade de entorpecente apreendido em poder dele. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica.

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, tendo em vista pequena quantidade e a natureza das drogas apreendidas, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de Maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado FRANCISCO MARCIO DE LIMA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime prisional inicial aberto, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando o quantum de pena e regime aplicados, bem como a ausência de fundamentos para a decretação de sua custódia cautelar.

Fls. 14/15: O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Fls. 14/15: Quanto ao aparelho celular apreendido, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto ao dinheiro, aparelho celular e às drogas.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA